

1510311-39.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... tais condições, em ponto indicado como de tráfico, é de ser condenado nos termos da imputação inicial. Ressalte-se que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510311-39.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510311-39.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112016/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 17528289 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2385/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2112016 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINÍCIUS DA LUZ SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

VINÍCIUS DA LUZ SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, agindo em concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos com pessoa desconhecida, trazia consigo, para comércio 160 porções de "maconha", contendo tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 248,5g; 226 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 77,8g; 352 porções de substância que aparenta ser "ecstasy", contendo, com peso líquido de 4g ; 95 porções de cocaína, com peso líquido de 36,5g; e 06 frascos de "lança

perfume", contendo tricloroetileno, com volume líquido de 47ml, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo convertida sua prisão em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar à fl. 99.

A denúncia foi recebida às fls. 108/110 e depois foi o réu citado. Na mesma oportunidade, lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 79/82 dos autos.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O representante do Ministério Público se manifestou em debates orais, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovados os fatos descritos na denúncia diante da prova produzida. Requereu o afastamento do privilégio, a considerar a quantidade e variedade dos entorpecentes em poder do acusado, o que revela seu envolvimento na criminalidade.

A Defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 28-A, §14º, do Código de Processo Penal, o que foi deferido.

O processo seguiu à Procuradoria Geral de Justiça e, com a recusa na propositura do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, a Defesa se manifestou em memoriais escritos, arguindo preliminar de falta de justa causa para a propositura da ação penal, ante o não oferecimento do acordo de não persecução penal em favor do réu. No mérito, alegou que não há prova da autoria do crime com relação a parte dos entorpecentes, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em favor do acusado, assim como o cômputo da confissão quando da aplicação de sua pena, com fixação de regime mais brando para cumprimento da pena, substituição por restritiva de direitos e concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela combativa Defesa é inconsistente e por esta razão fica repelida.

Com efeito, o entendimento adotado por este juízo é o de que o acordo de não persecução penal não se trata de direito público subjetivo do acusado, podendo ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei nº 13.964/2019 no caso concreto.

E tal entendimento se constrói com base, notadamente, em entendimento pretérito do E. Supremo Tribunal Federal para hipótese análoga, vale dizer, negocial, quando da entrada em vigor da Lei 9.099/95, artigo 89. Naquela oportunidade, discutiu-se sobre a obrigatoriedade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo por parte do Ministério Público e a possibilidade de supressão judicial em caso de respectiva não apresentação, tendo a E. Corte firmado tese na linha de que o benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado, de forma que não caberia ao Juízo a designação de audiência para tal fim em caso de não propositura. Nesse sentido, a título exemplificativo: "HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDO DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95) OU À SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CP). ORDEM DENEGADA. O benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado. Presentes os pressupostos objetivos da Lei nº 9.099/95 (art. 89) poderá o Ministério Público oferecer a proposta, que ainda passará pelo crivo do magistrado processante. Em havendo discordância do juízo quanto à negativa do Parquet, deve-se aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do CPP, remetendo-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 696/STF). Não há que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público quanto ao oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Do contrário, o titular da ação penal seria compelido a sacar de um instrumento de índole tipicamente transacional, como é o sursis processual. O que desnaturaria o próprio instituto da suspensão, eis que não se pode falar propriamente em transação quando a uma das partes (o órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou não por ela. Também não se

concede o benefício da suspensão condicional da execução da pena como direito subjetivo do condenado, podendo ela ser indeferida quando o juiz processante demonstrar, concretamente, a ausência dos requisitos do art. 77 do CP. Ordem denegada" (STF, HC nº 84342/RJ, Min. Rel. Ayres Britto, Primeira Turma, J: 12/04/2005, DJe: 23/06/2005).

Assim é que, não havendo direito subjetivo do réu à propositura do negócio jurídico, não há que se reconhecer, em absoluto, a falta de justa causa ao manejo da ação penal, como alegado pela Defesa.

Aliás, nessa linha vem se consolidando a jurisprudência, cabendo conferir nos julgados do AgRg no REsp 1948350/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021; AgRg no RHC 152756/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1816322/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/04/2021, DJe 22/04/2021; AgRg no RHC 130587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020; RHC 154937/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, publicado em 19/11/2021; HC 701443/MS (decisão monocrática), Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2021, publicado em 05/11/2021).

Rejeitada a preliminar, no mérito a ação penal é de ser julgada procedente, a despeito da combatividade da Defesa.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e pelo laudo de exame químico toxicológico realizado, fls. 79/82, prova técnica que atestou serem maconha, cocaína, crack, ecstasy e lança perfume as substâncias apreendidas em poder do acusado.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo.

Na fase policial, o réu confessou a prática delitativa, informando que foi a segunda vez que traficava drogas e que pegava a droga com o rapaz que não sabe informar o nome, recebendo R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, das 18h00 as 13h00. Em juízo manteve a confissão. Alegou que não tinha experiência no tráfico, mas estava com as drogas apreendidas para vender. Ia ganhar R\$ 100,00 por turno de trabalho, doze horas. Uma pessoa desconhecida deixara a droga em um esconderijo e depois o interrogando deixaria tudo escondido para que pegassem, junto com o dinheiro. Já tinha vendido droga no mesmo local no dia anterior, ocasião em que conversou com o responsável pelas drogas, que lhe deu o dinheiro pelo turno de trabalho. No dia dos fatos estava em poder somente de maconha e cocaína. Resolveu traficar, porque estava desempregado.

Sua confissão foi corroborada diante das provas produzidas.

O policial Wellington esclareceu que estavam em patrulhamento na região dos fatos, porque o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o réu, que portava uma bolsa, dentro da qual encontram os entorpecentes apreendidos, em quantidade razoável, maior do que normalmente acontece. Pelo que se recordou o policial Wellington estava acompanhado de outra pessoa quando foi visto, mas o outro indivíduo conseguiu correr. A policial Thais não se recordou dos fatos e tampouco do réu que lhe foi apresentado em audiência, dando conta de que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas.

É diante do teor destes depoimentos que se autoriza a condenação do réu, já que absolutamente coerentes os relatos apresentados pelos policiais em juízo e em solo policial. Importa frisar que os depoimentos dos policiais não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes, ante a prova documental juntada, laudo e auto de apreensão, e, inclusive, a confissão -, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos.

E note-se que malgrado os policiais em juízo não tenham especificado qual a natureza das drogas que o réu trazia consigo, a fls. 11/12 foram relacionados os entorpecentes apreendidos na ação policial e, não tendo sido destacado pelos agentes públicos o encontro de drogas com outrem quando dos fatos, é evidente que

todas aquelas substâncias enumeradas no auto de apreensão estavam, de fato, em poder do denunciado, como explicitado nos depoimentos policiais, os quais devem ser considerados no cotejo com a prova judicialmente produzida.

Ademais, é de ser salientado que o réu sequer conhecia os policiais e que estes tampouco conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente.

Noutro giro, na medida em que tinha o réu quantidade razoável de entorpecente em porções individuais e foi encontrado, em tais condições, em ponto indicado como de tráfico, é de ser condenado nos termos da imputação inicial. Ressalte-se que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

Procedente a demanda, passo à dosimetria da pena.

O réu é primário, contudo, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva da droga – cocaína –, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, assim como a variedade das drogas encontradas, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Majoro a pena base em um sexto e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Relevo que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida – cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Não há circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, pelo que trago as penas aos mínimos, atenuando-as.

Na terceira fase, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo as penas na metade, estabelecendo-as em definitivo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na ausência de causas de aumento da pena.

Saliento que se aplica em favor do réu o benefício legal, vez que não se pode desde logo reconhecer nele a figura de criminoso contumaz, já que não ostenta antecedentes e os policiais mencionaram sequer conhecê-lo de outras diligências, não havendo qualquer elemento que indique a nem mesmo investigação prévia por outras atividades em desacordo com a lei que tivesse praticado.

Não se desconsidera o entendimento na linha de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas (AgInt no HC 241.207/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). No caso dos autos, porém e como se viu, não há qualquer outra circunstância que indicaria ao envolvimento com a criminalidade, daí aproveitar ao acusado o privilégio previsto em lei.

De outro lado, porém, aponta-se ao envolvimento, mesmo que ocasional, em atividade estruturada do comércio de drogas, dada, principalmente, a diversidade dos entorpecentes expostos à venda, além da organização do "negócio" indicada pelo próprio acusado em seu interrogatório, com entrega das substâncias por terceiro anônimo, em local previamente combinado e escondido, e devolução do dinheiro auferido também de forma anônima, fazendo-se uso de rádios comunicadores (também apreendidos).

Quanto ao regime de cumprimento da pena, vejo ser o réu primário e portador de bons antecedentes, não podendo se considerar, na linha do que decidiu o E. Supremo

Tribunal Federal tenha praticado crime hediondo. No contexto, fixo-lhe o regime aberto para desconto da pena.

Deixo de substituir esta pena corporal por restritiva de direito em razão da insuficiência desta reprimenda no caso em apreço à finalidade ressocializadora que se pretende emprestar à reprimenda, a considerar que o crime em cuja prática se viu envolvido o imputado remete a inúmeras outras práticas delituosas e que redes criminosas se formam por sua conta (artigo 44, III, do Código Penal). Neste sentido o v. acórdão que julgou a apelação nº 0065883-50.2014.8.26.0050, desta Comarca de São Paulo. Rel. Des. Cardoso Perpétuo, julgado em 09 de março de 2017, por v.u.: “é indubitável que não se pode ter como boas a conduta social e a personalidade de agente condenado por tráfico de entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição tal como pleiteada pela defesa. A medida não é socialmente recomendável e a benesse só daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que deve ser evitado”.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VINÍCIUS DA LUZ SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e à pena pecuniária 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, dado o regime de cumprimento da pena que lhe foi imposto.

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Autorizo a destruição do entorpecente e do rádio apreendidos, comunique-se. Declaro o perdimento dos valores em favor do FUNAD.

Custas, ex lege.

P.I.C.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA